

1502797-47.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS QUE NÃO SE AFIGURAM INERENTES AO TIPO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502797-47.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502797-47.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO MOREIRA GOMES DE MELO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

CARLOS EDUARDO MOREIRA GOMES DE MELO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas da denúncia, em ocasião de calamidade pública, subtraiu para si uma bicicleta de marca Barra Forte, aro 26, pertencente a A.S.S.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado e ofereceu resposta à acusação.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia, sendo homologada a desistência manifestada pelas partes quanto à oitiva das testemunhas policiais. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou, ainda, pedidos relativos à dosimetria da pena e fixação do regime prisional.

A Defesa, por sua vez, deixou de requerer a absolvição do réu, diante de sua confissão. Formulou pedidos relativos à fixação da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da circunstância agravante relativa ao estado de calamidade pública e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pugnou, outrossim, pelo reconhecimento da tentativa e, por fim, pela fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de furto descrito na denúncia está bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pelos demais elementos constantes nos autos.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou a prática do crime descrito na denúncia. Disse que estava sem dinheiro, precisando comprar mantimentos para sua casa, e decidiu furtar a bicicleta para vendê-la.

Corroborando a confissão do acusado, a vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório, declarou que havia encostado a bicicleta, sem prendê-la, para entrar em seu local de trabalho e, logo após, viu o réu subtraí-la, evadindo-se em sua posse, pedalando. Disse que foi ao encalço do acusado, com outros populares que estavam na rua, conseguindo conter o réu a cerca de duas quadras de distância do local dos fatos, recuperando a bicicleta. Afirmou que não teve dúvidas de que o indivíduo detido foi aquele que subtraiu seu bem.

A vítima não reconheceu o acusado em Juízo. Todavia, deve ser destacado que, por equívoco na unidade prisional, somente observado após o procedimento para reconhecimento, foram apresentadas três pessoas, dentre as quais nenhuma era o réu.

A testemunha Gabriel Souza Almeida Santana, ouvida em Juízo, narrou que, ao sair de uma loja, viu um indivíduo subtraindo uma bicicleta e fugindo em posse dela, pedalando-a. Relatou que viu a vítima no encalço do meliante, gritando e pedindo que populares o contivessem. Disse que um homem interceptou o meliante, fazendo com que ele caísse da bicicleta e, então, este continuou sua fuga correndo. Declarou que perseguiu o meliante, juntamente com outras pessoas, logrando êxito em contê-lo até a chegada da polícia militar ao local. Disse que o acusado caiu da bicicleta a cerca de 500 metros do local dos fatos e correu por mais um percurso até ser detido. Reconheceu o acusado em Juízo como sendo o autor do crime, sem dúvidas.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante das declarações da vítima e da testemunha presencial em Juízo, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, não há dúvidas em se concluir que o réu efetivamente praticou o delito de furto descrito na denúncia.

Malgrado a vítima não tenha reconhecido o acusado em Juízo, diante do que já foi ressaltado, a testemunha presencial o reconheceu, sem qualquer dúvida, como autor do crime.

As declarações apresentadas pela vítima e testemunha em Juízo complementam-se e são coerentes e harmônicas com suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Embora a confissão não seja prova dotada de caráter absoluto, no presente caso, ela está em conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, tendo sido confirmada pela prova oral produzida.

Assim, quanto às declarações da vítima, veja-se:

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si” (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250)

“Tribunal de Alçada Criminal - TACrimSP. PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que confortada por outros elementos probatórios, como o depoimento de uma testemunha, reveste-se de total importância.” (TACrimSP - Ap. nº 1.157.791/5 - Araraquara - 10ª Câmara - Rel. Ary Casagrande - J. 2.2.2000 - m.v).”

Dessa forma, o crime de furto e sua autoria restaram bem demonstrados nos autos.

Pelos elementos constantes dos autos e diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores que prestigia a Teoria da Apprehensio, verifica-se que o furto foi consumado, uma vez que o acusado conseguiu apoderar-se da res, invertendo a posse, independentemente de ter sido esta tranquila, mansa e pacífica.

Veja-se que vítima e testemunha presencial afirmaram que o acusado empreendeu fuga pedalando a bicicleta subtraída e foi detido já em local distante de onde ocorreram os fatos, por auxílio de populares que foram alertados para a ocorrência do crime.

Incide na espécie o Enunciado da Súmula nº 582 do E. Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.”

E nesse sentido, confirmam-se as decisões que confirmam o mesmo entendimento quanto ao delito de furto:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I - A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desviada da coisa pelo agente. Precedentes. II - O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminoso praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. IV -

Habeas Corpus denegado." (HC 135674, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016) (grifos nossos)

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 582/STJ. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DETRAÇÃO. AINDA QUE APLICADA, NÃO REDUZIRIA A PENA PARA PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS. REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL APROVEITAMENTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Dessa forma, prevalece, tanto nesta Corte Superior quanto no Supremo Tribunal Federal a teoria da amotio ou apprehensio. 3. Inclusive, esse entendimento foi consolidado recentemente no enunciado n. 582 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 5. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de três majorantes, decorreu de peculiaridades concretas do crime - cinco agentes envolvidos na empreitada criminoso, com emprego de arma de fogo, com invasão de domicílio, e amarração de duas vítimas. Em tais condições, fica afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte. 6. "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito" (enunciado n. 440 da Súmula do STJ) e, no mesmo sentido, os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF. 7. No caso, embora os pacientes sejam primários, condenados à pena privativa de liberdade superior a 4 e não excedente a 8 anos, o regime mais gravoso foi estabelecido mediante fundamentação concreta, qual seja, ameaça a duas vítimas, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e mediante invasão de domicílio. 8. O cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, conforme o comando do § 2º do art. 387 do CPP, demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal. 9. No caso, verifica-se que, mesmo aplicada a regra da detração, o tempo de prisão provisória não reduziria a pena para patamar inferior a 4 anos, sendo o regime mais gravoso fixado com base em fundamentação concreta, razão pela qual a efetiva detração de eventual pena cumprida de forma provisória seria irrelevante. 10. Habeas corpus não conhecido." (HC 362.436/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016) (grifos nossos)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade

nas hipóteses em que a decisão monocrática for proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP. 2. Esta Corte adotou o entendimento no sentido da teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual os crimes de roubo e de furto, consumam-se no momento em que os agentes se tornam possuidores da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica, tranquila ou mesmo desvigiada. 3. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1524450/RJ, Representativo da Controvérsia, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/10/2015) . Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 787.872/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016) (grifos nossos)

Desta maneira, restou provada a prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo, portanto, a dosar a pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado é detentor de maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 17, motivo pelo qual aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o crime foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. Destaque-se, ainda, que, o uso de máscaras de proteção facial em espaços de acesso público localizados no território estadual, como medida para conter a disseminação da COVID-19, conforme disposto no Decreto nº 65.897 de 30 de julho de 2021 do Estado de São Paulo, permaneceu vigente até o dia 08 de setembro de 2022, quando tais medidas foram liberadas por meio do Decreto nº 67.096. Saliente-se, ainda, que, embora sem revogação expressa do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública neste estado, deve-se considerar que as medidas de contenção contra o avanço do novo coronavírus permaneceram vigentes até 08 de setembro deste ano de 2022 quando, por parecer do Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo, verificou-se possível esta flexibilização dos regramentos.

A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto,

o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em 1/6, ficando ela fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ainda nesta etapa, verifico que o acusado é reincidente pela prática de mesma espécie de crime contra o patrimônio, conforme certidão criminal de fls. 19 e 22, razão pela qual deve a pena ser acrescida em 1/3, ficando fixada em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Consigno que não haveria que se falar em bis in idem no aumento de pena na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena em razão de existência de duas condenações criminais transitadas em julgado. Esse é o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, confirmado em decisão recente:

"HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS QUE NÃO SE AFIGURAM INERENTES AO TIPO PENAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA JUSTEZA DA REPRIMENDA NO ÂMBITO DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena, circunstância esta não evidenciada na hipótese. Precedentes. 3. O aumento da pena-base acima do mínimo legal, quanto ao crime de resistência, restou suficientemente fundamentado, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Paciente especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. Isso porque, conforme consignou o Juízo sentenciante, o Acusado, no momento de sua prisão, ofendeu a integridade física de policial militar e incitou populares e familiares a agredi-lo, instigando-os, inclusive, a subtrair a arma do miliciano. 4. Não havendo ilegalidade ou abuso de poder na individualização da pena-base, essa via não é adequada para dizer se foi justa ou não a reprimenda aplicada ao Paciente. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus denegada." (STJ - HC 213240/SP 2011/0163921-1. Rel. Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. Data do Julgamento 05/09/2013 DJE 11/09/2013).

Reconhecida também a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduz a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor já estabelecido.

Fica consignado que, diante da reconhecida reincidência específica do réu, que se verifica ser também múltipla no presente caso, é incabível a compensação integral desta circunstância agravante com a circunstância atenuante da confissão espontânea.

O Código de Processo Penal, embora não mais cuide detalhadamente do instituto da reincidência específica, contém ainda dispositivos que diferenciam os institutos da reincidência genérica e da específica, dando a esta última tratamento mais severo.

São exemplos o artigo 44, §3º e o artigo 83, V.

No mesmo sentido já entendeu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao examinar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.154.752/RS, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo, contudo, o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 2. No caso em análise, trata-se de paciente reincidente específico no crime de furto qualificado, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, inviabiliza a almejada compensação integral. (...)
(HC 360.588/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017 - grifei)

HABEAS CORPUS. ROUBO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO. LEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE GENÉRICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. É razoável a fixação da pena-base do crime de roubo 8 meses acima do mínimo legal ante os maus antecedentes do réu, principalmente ante a reiteração no cometimento de crime de natureza patrimonial, com violência ou grave ameaça contra pessoa. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, apesar de não estabelecida pela norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a adoção de percentual superior mediante fundamentação concreta (multirreincidência, reincidência específica). 3. Se a confissão do réu foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação. 4. No julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. A compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a natureza e os graus de reincidência. 5. Não é possível realizar a compensação integral entre a confissão e a reincidência, ante a reincidência específica do réu. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 5 anos de reclusão mais 12 dias-multa. (HC 258.693/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016 - grifei)

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a reprimenda acima estabelecida.

Fixo ao acusado o regime fechado como regime inicial do cumprimento da pena, diante de sua reincidência e das circunstâncias judiciais negativas.

Pelos motivos acima expostos, não estão presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, de modo que deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos sendo, pela mesma razão, também incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito dos seus comportamentos no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso

que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO MOREIRA GOMES DE MELO, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a prisão preventiva. O acusado é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são negativas. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Ausente demonstração mínima dos integrais prejuízos sofridos pela vítima, bem como pela ausência de pedido nesse sentido na denúncia, deixo de condenar os réus nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação do ofendido a ser perseguido na esfera cível.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 08 de novembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA